

1510380-62.2016.8.26.0223

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública

Magistrado: André Rossi

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

Foro de Guarujá

2ª Vara Criminal

Rua Silvio Daige, 280, Guarujá-SP - cep 11490-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1510380-62.2016.8.26.0223 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1510380-62.2016.8.26.0223

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Outras Substâncias Nocivas a Saúde Pública

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 160/2016 - DEL.INV.GER. SANTOS, 29790 - DEL.INV.GER. SANTOS, 748/2016 - DEL.INV.GER. SANTOS, 748/2016 - DEL.INV.GER. SANTOS, 748/2016 -

DEL.INV.GER. SANTOS, 748/2016/201 - DEL.INV.GER. SANTOS, 160 -

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDNEIDE CRISTIANE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). André Rossi

Vistos.

EDNEIDE CRISTIANE DA SILVA, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso nas sanções do art. 273, parágrafo 1º-B, inciso I do Código Penal, porque, em data incerta, mas durante o ano de 2016, na Avenida Tancredo Neves, numeral 1243 - Santa Clara Travessa Castro Alves, numeral 248, local que abrigava a farmácia "Mega Farma", nesta comarca, em comunhão de esforços e unidade de desígnios com Evandro Rocha Lopes, Eliana Cardoso de Oliveira e Gislene dos Santos de Oliveira, já condenados criminalmente pelos mesmos fatos, vendeu e entregou reiteradas vezes, para fins de consumo de terceiros, comprimido do medicamento Cytotec, fazendo-o sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta na denúncia que nas condições de tempo e de espaço acima apuradas, a acusada adquiriu pílulas abortivas Cytotec de Evandro e Elaine pela quantia de R\$ 250,00, revendendo tais medicamentos para conhecidos seus pelo valor de R\$ 450,00, ocorrendo tais fatos com certa frequência.

Consta que, nesse ínterim, deflagrou-se a operação "MÚLTIPLO", executada pela Delegacia de Investigações Gerais de Santos/SP, a qual obteve êxito na prisão de Evandro Rocha Lopes, Eliana Cardoso de Oliveira e Gislene dos Santos de Oliveira, todos denunciados e condenados em primeira instância pela prática do crime previsto no art. 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal (Ação penal nº 1500889-62.2016.8.26.0536 em trâmite perante a 1ª Vara Criminal desta comarca) pois mantinham em depósito, para fins de venda, distribuição ou entrega a terceiros, sem registro no órgão de vigilância sanitária competente, 10 (dez) cartelas do medicamento Pramil, perfazendo o total de 220 (duzentos e vinte comprimidos), 14 (quatorze) ampolas de Primobolan Depot, 58 (cinquenta e oito) ampolas de Durateston, 94 (noventa e quatro) ampolas de Decadurabolin, 3 (três) ampolas de Adrenalina, 3 (três) aplicadores vaginais, 6 (seis) cartelas de Digram, com 10 (dez) comprimidos cada cartela, 2 (duas) cartelas de Pramil, com 20 (vinte) comprimidos de Pramil, 2 (duas) caixas contendo 60 (sessenta) comprimidos de Carbamazepina, 1 (uma) ampola de Durateston, 1 (uma) caneta aplicadora contendo 7 (sete) agulhas, marca Victoza, 12 (doze) comprimidos do medicamento Cytotec, 2 (duas) cartelas de Oxitoland Oximetolona, 2 (duas) cartelas de Cimelide, 3 (três) canetas de aplicação Victoza, 2 (duas) cartelas de Metronidazol e 2 (duas) cartelas de Torsilaxi, produtos destinados a fins medicinais.

Consta também que durante a operação supracitada, interceptações telefônicas revelaram que a ré interagiu com Evandro Rocha Lopes, Eliana Cardoso de Oliveira e Gislene dos Santos de Oliveira, a fim de intermediar a venda e entrega de pílulas abortivas a terceiros que a procuravam no balcão da farmácia Mega Farma, local em que trabalhava como balconista.

Consta ainda que na delegacia de polícia a ré confirmou a venda e intermediação, aduzindo que à época dos fatos passava por dificuldades financeiras.

A denúncia foi recebida em 13 de julho de 2020 (fls. 376). A ré foi citada e apresentou resposta à acusação (fls. 339 e 400/401). Mantido o recebimento da denúncia (fls. 407/408), foram ouvidas as testemunhas e a ré interrogada (fls. 434/437).

Em memoriais o Ministério Público requereu a condenação da ré nos termos da denúncia (fls. 441/448), enquanto a d. Defesa pugnou pela absolvição sustentando insuficiência probatória e, subsidiariamente, requereu a aplicação por analogia do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, a fixação do regime aberto, a substituição da pena corporal por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (fls. 459/474).

É o relatório.

DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitativa vem demonstrada pelo termo de declarações a fls. 75, transcrições de interceptações telefônicas a fls. 83/84, relatório a fls. 94/101, bem com, de resto, pela prova oral colhida.

A autoria criminosa igualmente é certa e será atribuída à ré.

Perante a autoridade policial a acusada confessou a prática criminosa, aduzindo o

seguinte:

“Que, a declarante informa que trabalha como Balconista na Farmácia Mega Farma, de propriedade do Sr. Lincoln. A Declarante informa que lá na região do bairro Cachoeira, todos sabem que “Baby” e “Fia”, comercializam o medicamento Cytotec, utilizado para prática abortiva. A Declarante, por motivos de necessidade financeira, acabou intermediando a venda do medicamento para uma pessoa que lhe procurou na farmácia, onde trabalha. Efetuou o contato com “Fia” e adquiriu o medicamento. Recebeu a quantia de R\$ 400,00 e entregou para “Fia” a quantia de R\$ 250,00, por quatro comprimidos de Cytotec. Afirma que o Farmacêutico não teve conhecimento do fato e afirma, ainda, que chegou a fazer outras intermediações, pois enfrentava dificuldade financeiras, assim, quando foi procurada na farmácia, realizou a intermediação para obter lucro. Ressalta que não possui nenhum vínculo de amizade com o casal (“Baby” e “Fia”), desconhecendo até o endereço deles. Mantinha contato com eles pelo seu telefone de nr 99692-2418. Observando o álbum de fotografias, reconheceu nesta oportunidade Evandro Rocha Lopes e Eliana Cardoso de Oliveira, como sendo “Baby” e “Fia”, as pessoas que realizam o comércio de Cytotec lá na região da Cachoeira, no Guarujá/SP” (fls. 75).

Em juízo a ré se retratou, passando a negar os fatos descritos na denúncia. Afirmou que a medicação abortiva não era comercializada pela farmácia, tampouco, por ela. Por se tratar de uma farmácia, algumas pessoas procuravam no estabelecimento a medicação abortiva. Apenas repassava a informação conhecida no bairro de que determinado casal vendia o medicamento. Não sabia se de fato o medicamento era vendido pelo casal, mas tal informação era de conhecimento de todos na região. Não possuía relação de parentesco ou amizade com essas pessoas. Nunca intermediou tais supostas vendas ilícitas de medicamentos e jamais recebeu dinheiro por tais atos. Também não informava contato ou endereço do casal, apenas falava às pessoas interessadas no medicamento procurarem por “Fia” e “Baby”. Desconhece os nomes de tais indivíduos. Uma vez conversou por telefone com um dos dois, não se recordando se com “Fia” ou com “Baby”, ocasião em que solicitou o medicamento abortivo. Nunca possuiu o número telefônico de nenhum dos dois, mas na data em questão solicitou aludido número aos familiares do casal. Solicitou o número telefônico quando um dos familiares do casal esteve na farmácia onde a ré trabalhava. Não se recorda do teor da conversa, lembra-se apenas de ter solicitado medicamento Cytotec. Solicitou aludida medicação a fim de entregá-la a uma sobrinha que tinha a intenção de praticar aborto, porém, tal não foi realizado, sequer chegou a pegar o medicamento. Apesar de ter efetuado ligação a “Fia” ou “Baby” não chegou a combinar preço ou local de entrega do produto. Somente solicitou o medicamento, perguntou se a pessoa o possuía, porém, não obteve informação sobre preço ou local de entrega. Esse foi o único contato que manteve com “Fia” ou “Baby”. Não possui inimizades e não sabe por qual razão esta sendo acusada injustamente do crime. Trabalhou na farmácia por aproximadamente dois anos e pediu desligamento. Não conhece Polyana. Lincoln é filho do dono da farmácia, nada tendo contra ele. Conhece Eliana, porém, apenas pelo apelido de “Fia”. Conhece o delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Junior apenas por conta reportagens, nada tendo contra ele. Nunca havia sido processada criminalmente. Não conhece a filha da “Fia”, tampouco sabe o nome dela, porém, já a viu na farmácia. Desconhece Tainara. Na farmácia a declarante era chamada de “Tia Neidinha”. Não se recorda do número telefônico que possuía no ano de 2016. Recordase que a polícia realizou busca na farmácia, mas nada de ilícito foi encontrado. A farmácia ficava próxima à residência de “Baby” e “Fia”. Ambos eram muito conhecidos no bairro. O medicamento Cytotec geralmente era procurado por meninas novas. A acusada era procurada pelo fato de que trabalhava em uma farmácia. Não foi realizada nenhuma busca em sua residência e em seu poder nada de ilícito foi encontrado no decorrer das investigações (fls. 432 e 437).

A versão sustentada pela acusada somente em juízo, porém, se mostra inaceitável, pois contraria os seguros elementos de prova produzida no decorrer da instrução.

A testemunha delegado Luiz Ricardo de Lara Dias Junior relatou que no ano de 2016, dentre as atribuições da delegacia em que atuava, havia determinação específica quanto ao combate ao roubo de cargas, o que deu ensejo a diversas interceptações telefônicas, uma vez que foi identificada uma organização criminoso na cidade de Guarujá. Tal operação foi exitosa, identificando todos os membros da organização e também revelando a existência de micro organizações criminosas que comercializavam anabolizantes de circulação proibida e medicamentos abortivos, principalmente o Cytotec. Toda a investigação correu pela 2ª Vara Criminal e culminou na expedição de mandados de busca e apreensão, na nomeada operação "Múltiplo". Especificamente em relação à ré, apurou-se que ela integrava grupo criminoso que era liderado por indivíduo que atendia pela alcunha de "Baby" (Evandro), a esposa dele Eliane ("Fia") e Gislene. Durante o período de monitoramento dos diálogos entre tais indivíduos ficou comprovada a venda de anabolizantes e medicamentos abortivos por eles. Quando do cumprimento dos mandados de busca e apreensão nas residências de Evandro, Eliane e Gislene foram apreendidos medicamentos dessa espécie, não só anabolizantes como também comprimidos de Cytotec, o que subsidiou a prisão em flagrante deles. Não se recorda se ao tempo do cumprimento de tais mandados a ré já havia sido completamente qualificada, identificada ou se foi realizada busca e apreensão na residência dela, porém, recorda-se que ela foi ouvida durante a investigação e na delegacia de polícia confessou a intermediação de venda desse tipo de material, aduzindo tê-lo feito por conta de necessidade financeira. Na ocasião a acusada confirmou que recebia medicamentos que eram entregues por Evandro e Eliane pelo valor de duzentos e cinquenta reais e que os comercializava por quatrocentos e cinquenta reais a pessoas que procuravam a drogaria situada em Vicente de Carvalho. Na ocasião também foi ouvido o proprietário da farmácia, mas a própria ré narrou que ele de nada sabia, aduzindo que ela realizava o comércio por conta própria utilizando as dependências da farmácia na qual trabalhava. A farmácia era antiga e ficava no mesmo bairro da casa de Eliane e Evandro. Na fase extrajudicial a ré revelou e também foi comprovado pelas interceptações telefônicas que as pessoas a procuravam na farmácia em busca desse tipo de medicamento. A ré também revelou ter feito isso por diversas vezes. Algumas delas foram sedimentadas no curso de interceptação telefônica, restando ao final constatado que a ré realizou essa prática por dezenas de vezes. Não se recorda se na farmácia foi realizada busca. Acredita que foi realizada busca na casa da ré, mas pode estar equivocado. Recorda-se que as transações foram feitas entre a acusada e Eliane ou Evandro, por meio de ligações telefônicas. Ressaltou que no distrito policial a acusada confessou que adquiria os comprimidos do aludido casal por duzentos e cinquenta reais e os revendia às pessoas que a procuravam na farmácia por quatrocentos e cinquenta reais. A farmácia ficava no mesmo bairro da residência de Eliane e Evandro (fls. 432 e 434).

A testemunha Lincoln Francisco Gomes de Miranda afirmou que a ré foi sua funcionária na farmácia por cerca de dois anos. À época dos fatos administrava a farmácia, que era de sua família. Seu pai tinha problemas renais crônicos então contratou a acusada para ser balconista no estabelecimento, pois a testemunha se ausentava com frequência para auxiliar o genitor no tratamento médico em São Paulo. Ficou surpreso ao saber que a ré vendia Cytotec. Tomou conhecimento de tal fato somente quando foi intimado para depor na Delegacia Regional de Santos. Sabia que a ré tinha esse contato com Evandro e Eliana como amigos, mas não sabia que eles comercializavam medicamentos. Conhecia ambos apenas como vizinhos. Tinha conhecimento que Evandro e Eliana conversavam com a acusada, mas desconhece qual seja o grau de amizade entre eles. Na farmácia não havia Cytotec, tal medicamento não era comercializado. Soube na delegacia de polícia que por meio de interceptações telefônicas foram captados diálogos em que os envolvidos ajustavam entre si de levar o medicamento à farmácia aproveitando-se de sua ausência. A farmácia ficava situada próxima à casa dos parentes de Eliana. Evandro e Eliana eram bastante conhecidos na região, moravam na região havia muitos anos. Não se recorda se foi realizada busca na farmácia. Nunca presenciou atividade suspeita por parte da ré. A acusada parecia ter contato com Eliana e Evandro (fls. 432 e 435).

A testemunha Polyana Rodrigues da Silva aduziu desconhecer "Baby". Disse conhecer apenas "Fia" (Eliana), pois a genitora da declarante cuidava de "Fia" e de seus irmãos quando pequenos. À época dos fatos não tinha conhecimento do que Eliana vendia. Sabia que ela era manicure e vendia roupas, prata e remédios de academia/vitamina. Acerca do remédio abortivo ficou sabendo somente depois. Desconhece que "Fia" conhecesse alguém da farmácia. Sequer conhece a farmácia descrita na denúncia. Foi chamada para depor e ficou sabendo que "Fia" tinha envolvimento com os remédios e com o "cara" da farmácia. Não conhece "Tia Neidinha". Em juízo reconheceu como sua a assinatura constante do termo de declarações a fls. 60/61. Afirmou que durante o depoimento prestado na delegacia de polícia não sofreu nenhum tipo de coação, nem lhe foi exigido que dissesse algo. Por fim, alegou que após seu depoimento no distrito policial lhe disseram que deveria assinar o papel, mas não leu o termo de depoimento (fls. 432 e 436).

Nessas condições, a inocência sustentada pela ré somente em juízo não convence.

Verte dos autos que durante a operação "MÚLTIPLO" executada pela Delegacia de Investigações Gerais de Santos/SP, que resultou na prisão em flagrante de três indivíduos, Evandro Rocha Lopes ("Baby"), Eliana Cardoso de Oliveira ("Fia") e Gislene dos Santos de Oliveira, pela prática do delito capitulado no art. 273, § 1-Bº, inciso I, do Código Penal, interceptações telefônicas revelaram que a ré, também conhecida pelo apelido "Tia Neidinha", titular do número telefônico (013-99692-2418), interagiu com os indivíduos acima citados Evandro e Elaine a fim de intermediar a venda e entrega de pílulas abortivas a terceiros que a procuravam no balcão da farmácia Mega Farma, local em que trabalhava como balconista.

Na fase extrajudicial, perante a autoridade policial a ré confessou ter adquirido e vendido a terceiro pílulas abortivas Cytotec, fornecendo detalhes a respeito de sua conduta criminosa. Disse que no bairro onde se deram os fatos era de conhecimento geral que os indivíduos conhecidos como "Baby" e "Fia" comercializavam o medicamento Cytotec. Revelou ter entrado em contato com "Fia" e desse modo adquirido pelo valor de duzentos e cinquenta reais o medicamento Cytotec, o qual revendeu a um terceiro pela quantia de quatrocentos reais. Aduziu que além desse episódio específico, realizou outras intermediações (compra e venda), alegando tê-lo feito, pois passava por dificuldades financeiras. Revelou que para adquirir o medicamento realizava contato telefônico com os indivíduos "Baby" e "Fia" por meio de seu aparelho celular número 99692-2418.

Em juízo embora tenha se retratado em relação à confissão extrajudicial, alegando sequer se recordar de seu número telefônico à época dos fatos, a acusada admitiu que era conhecida na farmácia onde trabalhava pelo apelido "Tia Neidinha".

Tais fatos analisados em conjunto estão a confirmar ser a ré a autora das conversas captadas por meio de escuta telefônica, transcritas a fls. 83/84, em que uma pessoa identificada como "Tia Neidinha", utilizando-se do número telefônico (013) 99692-2418, entra em contato com "Fia" a fim de adquirir Cytotec pela quantia de duzentos e cinquenta reais com o intuito de revender o produto a uma terceira pessoa.

Por outro lado, a testemunha delegado de polícia Dr. Luiz Ricardo de Lara Dias Júnior, que presidiu o inquérito policial instaurado para apuração dos fatos descritos na denúncia, confirmou ter presenciado a confissão externada pela acusada no distrito policial a fls. 75.

Durante seu depoimento confirmou aludida testemunha que ao ser chamada à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos a ré confessou ter adquirido medicamento abortivo Cytotec de Evandro e Eliane ("Baby" e "Fia") pelo valor de duzentos e cinquenta reais para a revenda a terceiro pelo montante de quatrocentos e cinquenta reais. Relatou também que na ocasião a acusada admitiu ter realizado tal prática

criminosa por diversas vezes.

Aduziu a testemunha delegado de polícia civil que algumas das transações entre a ré e os indivíduos Evandro e Eliane foram interceptadas em escuta telefônica e que ao final das investigações restou evidenciado que a acusada cometeu o crime por dezenas de vezes.

Observo que nenhuma razão se demonstrou para que a testemunha delegado de polícia civil imputasse falsamente a prática delitiva à acusada.

Como é sabido, o valor dos testemunhos dos policiais é igual ao dos testemunhos de qualquer outra pessoa estranha aos quadros policiais.

O preconceito de que viriam eles em juízo com intuito inicialmente mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas, é despido de qualquer fundamento.

Não existe qualquer impedimento ou suspeição em relação a policiais, pelo só fato de serem policiais, no Código de Processo Penal vigente.

Aliás, seria de manifesto contrassenso o Estado credenciá-los para o exercício da repressão criminal e, ao depois, ao chamá-los para prestação de contas, perante o Poder Judiciário, deles retirar a credibilidade anteriormente depositada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

"TRÁFICO DE DROGAS. As provas colhidas indicam a prática do tráfico. No confronto entre a versão apresentada pela ré e sua filha e o depoimento das testemunhas policiais, que tem compromisso com a verdade, estes devem ser mais valorizados. Ausentes indícios de que os policiais visem imputar a prática delitiva a inocente. Mantida a condenação. Incabível a redução do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006. Inviável a substituição da pena ou sua suspensão. O regime fechado é o adequado. NEGADO PROVIMENTO AO APELO" (Apelação nº 0004707-61.2013.8.26.0032; Relator(a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Comarca: Araçatuba; Órgão julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/09/2014; Data de registro: 16/09/2014).

"Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo postulando a absolvição. Autoria comprovada pela palavra dos policiais que prenderam o réu em flagrante. Recurso desprovido" (Apelação nº 0002226-67.2008.8.26.0302; Relator(a): José Raul Gavião de Almeida; Comarca: Jaú; Órgão julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 16/12/2010; Data de registro: 28/12/2010).

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais firmes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Penas fixadas com critério - Inviabilidade, no caso, da aplicação do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Regime prisional inicial fechado mantido - Recursos desprovidos" (Apelação nº 0012236-97.2015.8.26.0344; Relator(a): Nelson Fonseca Junior; Comarca: Marília; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 24/11/2016; Data de registro: 25/11/2016).

Assim é que, a confissão extrajudicial a fls. 75 analisada em conjunto com os demais elementos de prova colhidos no decorrer da instrução, mormente o depoimento da testemunha delegado de polícia civil, colhido sobre o crivo do contraditório, a confirmar integralmente o teor da confissão externada pela acusada na delegacia de polícia e também os elementos indiciários apontados a fls. 83/84, resta evidenciado que ré é a autora da prática criminosa descrita na denúncia.

Registro, porém, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 979.962/RS (Rel. Ministro Roberto Barroso, julgado em 24/03/2021 – Tema 1003) decidiu pela inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal, determinando que à hipótese deve incidir o preceito secundário do art. 273 na sua redação originária. Nesse sentido:

“Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Importação de medicamentos sem registro sanitário (CP, art. 273, § 1º-B, I, do Código Penal). Inconstitucionalidade da pena abstratamente prevista. 1. O art. 273, § 1º-B, do CP, incluído após o 'escândalo das pílulas de farinha', prevê pena de dez a quinze anos de reclusão para quem importar medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária competente. 2. Como decorrência da vedação de penas cruéis e dos princípios da dignidade humana, da igualdade, da individualização da pena e da proporcionalidade, a severidade da sanção deve ser proporcional à gravidade do delito. 3. O estabelecimento dos marcos penais adequados a cada delito é tarefa que envolve complexas análises técnicas e político-criminais que, como regra, competem ao Poder Legislativo. Porém, em casos de gritante desproporcionalidade, e somente nestes casos, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário, para garantir uma sistematicidade mínima do direito penal, de modo que não existam (i) penas exageradamente graves para infrações menos relevantes, quando comparadas com outras claramente mais reprováveis, ou (ii) a previsão da aplicação da mesma pena para infrações com graus de lesividade evidentemente diversos. 4. A desproporcionalidade da pena prevista para o delito do art. 273, § 1º-B, do CP, salta aos olhos. A norma pune o comércio de medicamentos sem registro administrativo do mesmo modo que a falsificação desses remédios (CP, art. 273, caput), e mais severamente do que o tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33), o estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), a extorsão mediante sequestro (CP, art. 159) e a tortura seguida de morte (Lei nº 9.455/1997, art. 1º, § 3º). 5. Mesmo a punição do delito previsto no art. 273, § 1º-B, do CP com as penas cominadas para o tráfico de drogas, conforme propugnado por alguns Tribunais e juízes, mostra-se inadequada, porque a equiparação mantém, embora em menor intensidade, a desproporcionalidade. 6. Para a punição da conduta do art. 273, § 1º-B, do CP, sequer seria necessária, a meu ver, a aplicação analógica de qualquer norma, já que, com o reconhecimento da sua inconstitucionalidade, haveria incidência imediata do tipo penal do contrabando às situações por ele abrangidas. 7. A maioria do Plenário, contudo, entendeu que, como decorrência automática da declaração de inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, deve incidir o efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, que previa pena de 1 a 3 anos de reclusão. 8. Recurso do Ministério Público Federal desprovido. Recurso de Paulo Roberto Pereira parcialmente provido. Tese de julgamento: É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica repristinado o preceito secundário do art. 273, na sua redação originária. (...) 69. O excesso punitivo do preceito secundário da norma do art. 273, § 1º-B, I, representa um desses casos excepcionais, pois pune mais gravemente a importação e o comércio de medicamentos sem registro do que o homicídio, a tortura seguida de morte, o estupro de vulnerável e a extorsão mediante sequestro. 70. A pena mais adequada para a substituição do preceito secundário desproporcional, a meu ver, seria aquela prevista para o contrabando, de 2 a 5 anos de prisão (CP, art. 334-A), figura típica que representa o gênero de que as condutas tipificadas no art. 273, § 1º-B, I, são espécies. 71. Não obstante, curvou-me à compreensão esposada pela maioria do Plenário, reconhecendo a incidência do efeito repristinatório sobre o preceito secundário do art. 273, caput, do Código Penal, em sua redação original. 72. Diante do exposto, nego provimento do recurso do Ministério Público Federal e dou parcial provimento ao recurso de Paulo Roberto Pereira, determinando o retorno do processo ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a aplicação do preceito secundário previsto para o art. 273, caput, na redação original do Código Penal. Fixo a seguinte tese de julgamento: “É

inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimado o preceito secundário do art. 273, na redação originária" (RE 979962, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 24/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-113 DIVULG 11-06-2021 PUBLIC 14-06-2021).

Em consonância, o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 273, § 1º-B, I, DO CP. MATERIALIDADE DO DELITO. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRECEITO SECUNDÁRIO INCIDENTE NA ESPÉCIE. INOVAÇÃO RECURSAL. EXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO, COM A CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 1. Uma vez que ficou devidamente comprovado que o réu comercializou produtos terapêuticos sem o necessário registro junto à ANVISA - conforme, aliás, atestou o parecer técnico -, caracterizada está a materialidade do delito previsto no art. 273, § 1º-B, I, do CP, ainda que não tenha havido a realização de perícia nos produtos apreendidos. Precedentes. 2. Configura inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião do agravo regimental. 3. No julgamento do RE n. 979.962/RS (Rel. Ministro Roberto Barroso), com repercussão geral reconhecida, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.003): 'É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)'. 4. Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Concessão de habeas corpus, de ofício, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a fim de que aplique, em favor do acusado, a tese jurídica fixada pelo STF nos autos do RE n. 979.962/RS e, por conseguinte, realize a nova dosimetria da pena (Apelação Criminal n. 0006808-14.2009.4.03.6102/SP)" (AgRg no AREsp n. 1.404.621/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 26/5/2021 - negritei).

No mesmo sentido os julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Com efeito, registra-se que, para a fixação da pena, em relação às infrações ao artigo 273, parágrafo 1º-B, inciso I, do Código Penal, vinha sendo observado por esta Desembargadora a orientação de há muito firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, diante da sua desproporcionalidade, o preceito secundário do artigo 273, caput, e §§ 1º e 1º-B, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 9.677/1998, é inaplicável, e deve ser substituído pelo preceito secundário do crime de tráfico (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com possibilidade, inclusive, de aplicação da causa de diminuição instituída pelo § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, quando presentes os seus pressupostos. (...) Contudo, verifica-se que, recentemente, em 24.03.2021, ao julgar, em caráter de repercussão geral, o Recurso Extraordinário nº 979962/RS, de que foi Relator o Ministro Roberto Barroso, o Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, fixou a tese no sentido de que 'É inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal, com redação dada pela Lei nº 9.677/98 (reclusão, de 10 a 15 anos, e multa), à hipótese prevista no seu § 1º-B, I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária. Para esta situação específica, fica reprimado o preceito secundário do art. 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa)' (acórdão publicado no DJe de 14.06.2021 - destaque ausente no original). Portanto, não há razão para que seja adotado entendimento diverso no caso concreto em exame. A utilização do preceito secundário do artigo 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa),



deve ser estendida a todos os verbos do tipo penal (que aliás já eram previstos na antiga redação do artigo 273 do Código Penal), pena de conferir-se a réus processados pelo mesmo crime, embora com condutas diversas, mas equiparadas, tratamentos distintos, o que representaria afronta ao primado da isonomia. Aliás, é pertinente consignar que, no andamento do Recurso Extraordinário nº 979962/RS, acima mencionado, consta a oposição de Embargos de Declaração pela Defensoria Pública da União, com vista ao esclarecimento do acórdão prolatado pelo plenário do Excelso Pretório, exatamente para que seja sanada a omissão do julgado quanto à aplicação do preceito secundário do artigo 273, na redação originária (reclusão, de 1 a 3 anos, e multa) aos demais verbos do tipo penal. O recurso ainda está em processamento, mas o seu relator determinou que fosse colhida a manifestação da Procuradoria-Geral da República, 'Em vista dos possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração opostos pela DPU', o que reforça a necessidade de aplicação da tese, desde logo, ao caso em análise. Nesse sentido, inclusive, julgamento desta Câmara, em processo da Relatoria do Exmo. Desembargador Xavier de Souza, figurando como revisor o Desembargador Paiva Coutinho e como terceiro julgador o Desembargador Alexandre Almeida - Ap. 0042488-95.2013" (TJSP; Apelação Criminal 0000680-58.2016.8.26.0540; Relator (a): Maria Tereza do Amaral; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 06/10/2021; Data de Registro: 06/10/2021 - negritei).

"Nulidade - Inépcia da denúncia não verificada - Requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal atendidos - Preliminar rejeitada. Crimes contra a saúde pública - Artigo 273, 1º-B, incisos I, V e VI do Código Penal - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por atipicidade da conduta - Impossibilidade - Recurso da Defesa improvido. Dosimetria - Inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B do Código Penal - Aplicação da pena prevista na redação originária do dispositivo - Possibilidade - Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal (RE 979.962/RS) - Recurso da Defesa provido em parte para reduzir a pena do apelante/apelado. Pena-base acima do mínimo legal - Necessidade - Quantidade e diversidade de medicamentos - Circunstâncias do caso concreto que garantem maior reprovabilidade da conduta - Recurso do Ministério Público provido em parte para exasperar a reprimenda na primeira etapa no patamar de um terço. Causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06 - Pleito de afastamento prejudicado - Aplicação das penas previstas no artigo 273 do Código Penal em sua redação original - Recurso do Ministério Público improvido. Regime aberto - Viabilidade - Pena inferior a quatro anos - Primariedade - Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal - Recurso da Defesa provido em parte para fixar o regime mais brando. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Pleito de afastamento desacolhido - Requisitos do artigo 44 do Código Penal devidamente preenchidos - Recurso do Ministério Público improvido e da Defesa provido em parte para reduzir a prestação pecuniária para cinco salários mínimos. Restituição de bens - Não comprovação de que os equipamentos foram utilizados para o cometimento do ilícito - Recurso da Defesa provido em parte para autorizar a devolução. (...) Embora o fato apurado nos presentes autos não diga respeito a importação de medicamentos, o certo é que, no referido julgamento, a Corte Constitucional decidiu pela inconstitucionalidade do preceito secundário do artigo 273, § 1º-B do Código Penal e asseverou ser inadequada a aplicação das penas cominadas ao tráfico de drogas em equiparação, por ser medida que mantém a desproporcionalidade das penas face às condutas tipificadas. (...) Desse modo, a reprimenda será alterada com base no preceito secundário do artigo 273 do Código Penal em sua redação originária (reclusão, de um a três anos e multa). " (TJSP; Apelação Criminal 1503472-43.2019.8.26.0268; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Embu das Artes - 2ª Vara Judicial; Data do Julgamento: 06/04/2022; Data de Registro: 07/04/2022 - negritei).

Assim, bem demonstradas autoria e materialidade do delito atribuído à ré na denúncia, resta a fixação das penas, aplicando-se à espécie o preceito secundário

da redação original do art. 273 do Código de Processo Penal.

Atento aos critérios estampados no art. 59 do Código Penal, verifica-se que a ré é primária. No entanto, sua conduta merece maior grau de censurabilidade, pois visava obtenção de vantagem patrimonial com o comércio ilegal de substância conhecida e utilizada na indução de aborto ilegal, aproveitando-se da visibilidade que possuía por trabalhar em farmácia regular como forma de captar vítimas. Além disso, o crime foi praticado em comparsaria e envolvia quantidade significativa de medicamentos. Destarte, fixo a pena-base acrescida de um sexto sobre o mínimo legal: um ano e dois meses de reclusão e onze dias multa.

Reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena ao mínimo legal, ou seja, um ano de reclusão e dez dias-multa, atento à Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Inaplicável ao caso redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, pois o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 979.962/RS, em sede repercussão geral, ao reconhecer a inconstitucionalidade do preceito secundário do art. 273, § 1º-B, I, fixou entendimento pela repristinação do preceito secundário do art. 273, caput, na redação original do Código Penal, afastando a aplicação à hipótese dos ditames da Lei 11.343/2006.

Sobre a matéria o julgado do C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS, E ART. 273, § 1.º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO AO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 273, § 1.º-B, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. REPRISTINAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO ORIGINAL DO ART. 273 DO CÓDIGO PENAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA CORTE SUPREMA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. 1. Hipótese em que o Parquet busca afastar a minorante prevista no § 4.º da Lei n. 11.343/2006 reconhecida em favor do Recorrido, que foi condenado como incurso no art. 273, § 1.º-B, inciso I, do Código Penal. 2. A despeito do que julgou a Terceira Seção desta Corte na Revisão Criminal n. 5.627/DF, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 979.962/RS (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, julgado em 24/03/2021), decidiu que é inconstitucional a aplicação do preceito secundário do art. 273 do Código Penal à hipótese prevista no seu § 1.º-B, inciso I, que versa sobre a importação de medicamento sem registro no órgão de vigilância sanitária, determinando-se que, para esta situação específica, deve ser aplicado o preceito secundário do art. 273 na sua redação originária. 3. Recurso especial prejudicado. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para aplicar ao Recorrido o preceito secundário da redação original do art. 273 do Código Penal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 979.962/RS, redimensionando a dosimetria da pena” (REsp n. 1.870.212/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 25/11/2021).

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o aberto, favoráveis as circunstâncias judiciais e tendo em vista a primariedade da ré.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, e atento ao critério da suficiência da substituição, substituo a pena corporal por uma pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Incabível o sursis, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal e corrigido na forma do art. 49, § 2 do Código Penal.

Por fim, anoto não ser o caso de reconhecimento da prescrição retroativa.

Embora a incerta a data exata da comercialização do medicamento Cytotec pela ré descrita na denúncia, os documentos encartados a fls. 83/84 dão conta de que ela negociou a obtenção de tal produto para revenda em 03/09/2016. Por consectário lógico, a revenda do medicamento pela acusada somente por ter se dado na mesma data ou em data posterior, ao passo que a denúncia foi recebida em 13/07/2020 (fls. 376).

Assim, considerando que no caso presente a prescrição se dá em quatro anos (art. 109, inciso V, CP), verifica-se que entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia ou entre o recebimento da denúncia e a presente data, o lapso prescricional não foi atingido.

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação e CONDENO EDNEIDE CRISTIANE DA SILVA, qualificada nos autos, incurso no art. 273, parágrafo 1º-B, inciso I do Código Penal, (aplicando-se à espécie o preceito secundário da redação original do art. 273 do Código de Processo Penal) às penas de um ano de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de dez dias-multa calculados no mínimo legal, substituída a pena corporal por prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação.

Nos termos do art. 4º, § 9º da Lei Estadual nº 11.608/03, arcará a ré com o pagamento das custas processuais correspondentes a cem UFESP's, calculadas ao valor vigente à época do pagamento.

Ao trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial.

Oportunamente, ao arquivo.

P. I. C.

Guaruja, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA